

1500804-11.2021.8.26.0210

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500804-11.2021.8.26.0210 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500804-11.2021.8.26.0210

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Kayqui Junior Lellis da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. KAYQUI JÚNIOR LELLIS DA SILVA, qualificado nos autos a fls. 15, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia

28 de setembro de 2021, por volta das 19h30min, na Rua Alexandre Figueiredo Rodrigues nº 24, Bairro Campos Elíseos, nesta cidade e Comarca, teria trazido consigo e teria em depósito, com finalidade comercial, seis porções de maconha, com peso líquido de 7,06 g, bem como uma porção do mesmo entorpecente, com peso líquido de 164,39 g, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É da inicial que “policiais militares realizavam patrulhamento quando receberam a informação de que o denunciado estaria praticando tráfico de drogas no cruzamento da Avenida 25 com a Rua 46, local conhecido como ponto de venda de drogas. Assim, os policiais foram até o local, onde avistaram KAYQUI. Ele, ao perceber que seria abordado, empreendeu fuga, deixando cair ao chão 6 (seis) porções de maconha. Os policiais, então, se deslocaram até a residência de KAYQUI, ocasião em que conversaram com sua avó, que autorizou a entrada e, assim, procederam revista no imóvel.

Por ocasião da busca, os militares encontraram uma porção grande de maconha na cama do denunciado, momento em que KAYQUI chegou ao local e assumiu a propriedade da droga.

Ainda, em varredura no quarto do denunciado, foram localizados um caderno utilizado para anotações do tráfico e uma balança de precisão, cf. auto de exibição e apreensão de fls. 13/14.”.

A denúncia de fls. 83/84 foi recebida em 21 de outubro de 2021 (fls. 89). O Réu foi devidamente citado (fls. 101) e apresentou defesa preliminar em fls. 111/122, rejeitada a fls. 128/130. Na instrução da foi colhida prova oral e decretada a revelia do Réu (cf. fls. 160).

Em memoriais, o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia, reconhecendo o tráfico privilegiado, com imposição de regime aberto para cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 157/159).

O douto Defensor, por seu turno, a fls. 157/159, requereu a improcedência da ação por falta de provas.

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

Ao término da instrução processual e após uma atenta análise dos autos, é de se afirmar que a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está evidenciada no auto de prisão em flagrante de fls. 01/05, boletim de ocorrência de fls. 06/08, pelo auto de constatação de fls. 10/12, auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, no laudo pericial de fls. 76/78, pelo laudo de exame químico-toxicológico em fls. 98/100, bem como pela prova oral colhida durante a persecução penal.

A autoria é certa contra o Réu, que no inquisitorial laconicamente declarou ser usuário e que a droga foi adquirida para seu consumo, pagando por ela o valor de R\$ 237,00, negando, ainda, propriedade sobre a balança (cf. fls. 04), ao passo que não foi ouvido em Juízo devido sua revelia (cf. fls. 157/159).

O policial militar Bruno, na fase judicial, declarou que estavam em patrulhamento quando avistaram o Réu, conhecido dos meios policiais pela traficância, instante em que ele dispensou seis porções de maconha e empreendeu fuga. Como ele era conhecido, foram até sua residência e depois de conversarem com a avó do Acusado, ela permitiu que ingressassem ali para ver se ele estava em casa, sendo que em seu quarto localizaram a maconha além de anotações e uma balança. Durante a diligência

o Réu chegou em sua residência e assumiu a propriedade da droga, sendo que ele não aparentava estar sob efeito de entorpecente. Em linhas gerais, esse foi o teor do depoimento do policial militar Tarcísio, que ainda afirmou que o Réu assumiu a propriedade da droga, dizendo que era destinada ao tráfico.

A análise das provas indica que o Acusado infringiu o disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343, de 23.06.2006. Isso se deve porque o Réu tinha em depósito e trazia consigo, de forma injustificável, consideráveis porções de maconha, o que, aliado à forma em que estavam acondicionadas, o conhecimento que os policiais tinham que ele estaria traficando, sua admissão perante os policiais no momento de sua abordagem, bem como a localização de balança que continha resquícios positivos para cocaína (cf. fls. 76/78), confirmam o exposto na denúncia. Tais condutas apontam, destarte, que o Réu iria utilizar o entorpecente apreendido para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06. Oportuno salientar que “Nunca é demais lembrar, de outro lado, que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado” (TJSP, Ap. 990.09172372-0, 5ª C.D.Crim., Rel. Des. Pinheiro Franco, j. 03.12.2009).

Importante destacar que o fato dele ter fugido dos policiais, mas posteriormente comparecido em sua residência não induz a absolvição do Acusado, porque nas duas oportunidades ele possuía a droga, sendo situação, com a devida vênia, irrelevante para o deslinde do feito, mormente quando se percebe que se trata de uma cidade de pequenas dimensões territoriais, não demandando tempo entre ele fugir do local onde inicialmente encontrado e chegar até sua residência.

Nem se olvide pelo fato de a acusação se embasar somente no depoimento prestado por policiais, que é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade.

A condição funcional não os torna suspeitos, valendo, outrossim, o princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão, “Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que inocorreu nos autos.

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram” (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009).

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, há que se ponderar que malgrado primário, a grande considerável quantidade de droga apreendida com o Réu, de todo incomum para os padrões de apreensões de tráfico desta cidade, apontam maior perniciosidade de sua conduta, circunstância de especial gravidade, pois certo que o entorpecente iria abastecer o comércio criminoso nesta cidade por considerável período, sendo mais grave a consequência do crime.

Some-se a isso, nesta fase inicial, apreciando os parâmetros legais ditados pelo artigo 59 do Código Penal e pelo artigo 42 da Lei de Drogas, que ainda é o caso de majorar a pena-base, tendo em vista que o Réu, que recentemente atingiu a maioridade penal e, por isso, é primário (cf. fls. 31/32), mas quando menor de idade teve várias passagens por atos infracionais (cf. fls. 33/34), demonstrando que apesar de jovem persiste na prática de condutas antissociais, com claro indicativo da periculosidade do agente. Ressalto que se não é viável a majoração da pena ao fundamento de maus antecedentes por passagens pela Justiça menorista, é certo ser possível, nesta fase, seu aumento diante da existência de atos infracionais em decorrência da personalidade do agente, o que aqui se faz porque, mesmo atingindo a maioridade penal há pouco tempo, evidencia perseverança na prática de condutas antissociais que não podem ser ignoradas, verbis: "A Terceira Seção desta Corte firmou orientação de que 'os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social. Se os atos infracionais não servem, por óbvio, como antecedentes penais e muito menos para firmar reincidência (porque tais conceitos implicam a ideia de 'crime' anterior), não podem ser ignorados para aferir a personalidade e eventual risco que sua liberdade plena representa para terceiros" (RHC n. 63.855/MG, rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Dje 13/6/2016)". (STJ, RHC 96.158/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 14.08.2018).

Desse modo, deve a pena-base ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, em seu menor valor, à míngua da comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase da dosimetria, reconheço as circunstância atenuante da menoridade relativa, estampada no artigo 65, inciso I, do Código Penal, reduzindo aquela pena em 1/6 (um sexto), chegando ao patamar de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O Acusado não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que a forma como se desenhou os fatos, sendo ele conhecido pela traficância e por traficar considerável quantidade de entorpecente, vem a demonstrar que se dedica, indubitavelmente, à atividade criminosa do tráfico de drogas, porque ninguém mantém tamanha quantidade de droga se não for ligado ao crime organizado, uma vez que este não admite concorrência, sendo indicativo claro que ele não praticou o crime ao qual ora condenado de forma esporádica, agindo de forma repentina e incontrolável, mas em um verdadeiro meio de trabalho ilícito.

Nesse diapasão: "Para redução da pena, essencial que o réu seja 'primário', apresente 'bons antecedentes', comprove que 'não se dedique às atividades criminosas', assim como, 'nem integre organização criminosa'.

Evidente que essa causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas. E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a 2/3) devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência. Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder.

Ao julgador compete a análise do impulso, do fator determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, ou mesmo, se vem tomando aquela conduta como estilo de vida, para que possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa de redução" (TJSP, Ap. 0003548-

97.2014.8.26.0210, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, j. 30.07.2019).

O regime de cumprimento de pena adequado, por se tratar de crime equiparado ao hediondo, é o inicial fechado. Nesse panorama: "O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto, não só por previsão legal artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 como, também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas, considerado o § 4º, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem dúvida, crime grave.

Mas há os considerados hediondos.

Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo, absolutamente intolerável.

Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?

O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a cocaína e o 'crack', por exemplo, além de causarem dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de recuperação. Bem por isso que se trata de crime hediondo.

A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.

O legislador, com a edição da Lei nº 11.343/06, passou a punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.

Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminoso, poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.

Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que menos os preocupa" (TJSP, Ap. 0000555-39.2016.8.26.0557, 15ª C.D.Públ., Rel. Des. Poças Leitão, j. 01.02.2018).

Por outro lado, é vedada a concessão de sursis ou substituição por pena restritiva de direitos, pela ausência dos requisitos subjetivo e objetivo. Ressalto, quanto tal aspecto que, não obstante a decisão tomada no HC 97.256/RS, do STF, que não possui cunho vinculante, com a devida vênia, não se verifica compatibilidade lógica da pena restritiva com a natureza da infração, sendo que deveria a defesa fazer prova de que o Acusado possui condições da substituição da pena corporal, o que não é afastado nem mesmo diante da Resolução nº 5/2012 do Senado, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, porquanto esta deve se dar respeitando parâmetros preestabelecidos pela lei, notadamente porque o artigo 5º, inciso XLIII, da CF/88 determinou regime mais rigoroso na reprimenda de crimes hediondos e equiparados.

Relevo, ainda, que a disposição do artigo 44 do Código Penal, que trata da conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não é de aplicação automática, pois elenca os requisitos legais para tanto. Ali, em seu inciso III, estabelece que somente é aplicável a comutação quando a conduta social

do réu, além dos motivos e circunstâncias do delito, forem favoráveis. A simples prática do narcotráfico, este o flagelo de nossa sociedade, indica o sujeito ativo do crime como pessoa portadora de péssima conduta social, sendo que os motivos e circunstâncias do crime são, evidentemente, desfavoráveis. Para isso, basta se ter contato com um usuário de entorpecente para se verificar a miséria que se tornou sua existência (e de sua família), tão-somente pelo consumo daquilo que é oferecido pelo traficante (ainda que seja um “pequeno” traficante).

Para o crime de narcotráfico, circunstâncias como primariedade, bons antecedentes ou emprego lícito servem para fixar a pena aplicada, bem como, quando o caso, o critério redutor. Contudo, não viabilizam a conversão em pena restritiva ou mesmo a fixação em regime que não o fechado, em vista dos diplomas legais acima citados, pois insuficiente à repressão e prevenção desta infração equiparada que é ao crime delito hediondo no caso concreto, tendo em vista a grande quantidade de entorpecente apreendida, dando conta de que o Acusado não pratica esporadicamente o crime, o que foi fielmente retratado no depoimento dos policiais. Nesse sentido, lapidar excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, verbis:

“Ressalta-se que a decisão apresentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, em 27 de junho de 2012, reconhecendo e declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 tem seus efeitos 'restritos ao processo e às partes litigantes', não possuindo efeito 'erga omnes', até porque, não afastada pela Suprema Corte a natureza hedionda do delito de tráfico, justificando a imposição do regime mais gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a imposição de regime fechado para o crime de tráfico de entorpecente: HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012; HABEAS CORPUS 216.265/SP. Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02.06.2012; HABEAS CORPUS 199.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.08.2012; e HABEAS CORPUS nº 225.568/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe. 27.08.2012.

Não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, havendo a necessidade de pronunciar algumas considerações.

Com efeito, o Senado, na forma do artigo 52, inciso X da Constituição Federal e com olhos voltados para o julgamento do HC nº 97.256/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Resolução nº 05/2012, cujo teor é a suspensão da parte que obstaculizava a conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, inserida no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que não encarcerado.

Em vista o postulado implícito da proporcionalidade (HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios, Ed. Malheiros), que é uma espécie de norma jurídica derivada do devido, justo e adequado processo legal (FAIR TRAIL), não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo.

Nesse contexto, pondera-se: de onde viria o numerário para o traficante cumprir a prestação pecuniária? E mais: onde o traficante, disseminador de vício, cumpriria prestação de serviços à comunidade ou entidade pública? Nas escolas? Nas creches? Nos orfanatos? Nos abrigos? Nos hospitais?

Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial do 'DUE PROCESS OF LAW'.

Além disso, é válido ressaltar que os recentes arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça indicam que não há ilegalidade na negativa de permuta, quando fundada na multiplicidade e na natureza lesiva das drogas apreendidas, isso porque a conversão

da sanção reclusiva não seria suficiente para a prevenção e a repressão do delito denunciado (HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe 15/02/2012). E, na espécie, como foram apreendidas porções consideráveis de 'maconha', a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, inciso III, do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da atividade ilícita" (TJSP, Ap. 0005407-56.2011.8.26.0210, 4ª C.D.Crim., Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 18.12.2012).

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, porquanto o crime apurado é classificado como vago, assim entendido aquele que tem por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

III. Isto posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência CONDENO o Réu KAYQUI JÚNIOR LELLIS DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em seu menor valor, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, vedadas a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Tendo em vista que o Acusado respondeu em liberdade este processo, não se mostra necessária a decretação de sua prisão cautelar, podendo aguardar o julgamento em liberdade, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

São devidas custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Guaíra, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA